

1500553-05.2021.8.26.0400

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Luiz de Abreu Costa

Comarca: Olímpia

Foro: Foro de Olímpia

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/09/2022

... a efetiva prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da LD), equiparado ao tráfico ilícito de drogas (art. 33, § 1º, da LD) ou de tráfico ilícito de maquinismos relacionados ao processamento de drogas (art. 34, caput, da LD).

Daí ser desnecessário apreender a droga ou examiná-la.

Valho-me, pois, dessa explicação.

Nos termos do art. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Olímpia - Vara Criminal

Praça Monteiro Lobato, 377, Centro - CEP 15400-000, Fone:

(17)3281-1927, Olímpia-SP - E-mail: olimpiacr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30 às 19h

1500553-05.2021.8.26.0400- lauda

Conclusos os autos ao MM. Juiz em 5 de setembro de 2022.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500553-05.2021.8.26.0400

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Parte processada:

SARA NERY DA ROCHA e outro

I - DO RELATÓRIO

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou a parte processada André de Jesus Sartorelio e Sara Nery da Rocha, devidamente qualificada, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas, LD) e art. 35, caput, da LD (fls. 222/224).

Determinou-se o processamento (fls. 225/227).

A parte processada, devidamente notificada (fls. 244 e 246), apresentou resposta escrita (fls. 254/255). Argumentou, ao lado de questões preliminares ao recebimento da denúncia, teses absolutórias (art. 386 do CPP).

Enfrentadas as alegações, a denúncia foi recebida em 27 de outubro de 2021 (fls. 260/263) e, conseqüentemente, designou-se audiência de instrução, debates e

juízo.

A parte processada foi citada pessoalmente (fls. 336 e 338).

Em audiência (fls. 419/420 [TA]), foram inquiridas duas testemunhas arroladas em comum; ao final, a parte processada foi interrogada.

Declarou-se encerrada a instrução (v. TA).

Em alegações finais (fls. 430/434), o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, argumentando que estão provadas a materialidade do contexto fático denunciado e a autoria delitiva.

De sua vez, a Defesa requereu a improcedência da ação penal (TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Habeas Corpus Criminal n. 2257842-55.2019.8.26.0000, da 3ª Vara Judicial da Comarca de Bebedouro – Rel. Des. REINALDO CINTRA TORRES DE CARVALHO, V.U., j. 25/01/2020), argumentando que não existe prova suficiente para a condenação (art. 386 do CPP); na hipótese de condenação, a aplicação da pena com observância das circunstâncias atenuantes e causas de diminuição de pena previstas em lei (fls. 437/443).

II – DOS FUNDAMENTOS

Antes de discutir o mérito, não há alegação preliminar.

2.1 Da materialidade dos fatos e da autoria delitiva

A ação penal é, em parte, procedente.

Certa a materialidade de um dos contextos fáticos descritos na denúncia, pela leitura do boletim de ocorrência (fls. 14/16 [B0]), do auto de exibição e apreensão (fls. 17 [AEA]) e dos laudos periciais toxicológicos provisório (fls. 56/58) e definitivo (fls. 241/242 [LPTox]), a autoria, conforme prova testemunhal produzida (v. TA), segue a mesma sorte de certeza (demonstração e comprovação).

Contextualizo e, ao final, explico.

A testemunha Eliezer Roberson dos Santos, que é membro da Polícia Militar, declarou, perante a autoridade policial (fls. 02), que: "realizavam patrulhamento pelo bairro Santa Ifigênia, na cidade de Olímpia, quando na rua Amélia Rodrigues Puttini, cruzamento com a rua Miguel Said Aidar, avistaram André entregando algo para um motociclista, quando então procederam abordagem em André, enquanto que o motociclista se evadiu sem ser identificado, oportunidade em que procedida revista pessoal, encontraram em seu poder, mais precisamente no bolso de sua bermuda, 09 (nove) pinos plásticos, contendo cocaína em seu interior e ainda uma cédula de vinte reais que André "dispensou" quando percebeu que seria abordado. Durante a abordagem feita em André, uma mulher conhecida nos meios policiais se aproximou, sendo identificada como Sara Nery da Rocha, companheira de André, a qual ao perceber que também seria revista, repentinamente pegou uma sacolinha plástica que estava ao lado de um poste na via pública, empreendendo fuga, ocasião em que a soldado Larissa foi ao seu encalço, conseguindo detê-la com o apoio de outra guarnição, quando conseguiram detê-la, tendo Sara "dispensado" aquela sacola plástica, onde em seu interior estavam acondicionados 40 (quarenta) pinos plásticos, também contendo cocaína em seu interior e idênticos aos pinos plásticos que foram localizados em poder de André. Diante do exposto, deram voz de prisão para o casal André e Sara, conduzindo-os até esta Unidade Policial." Em Juízo, confirmou as suas declarações extrajudiciais.

A testemunha Larissa Fernanda de Oliveira Gomes Saldanha, que é membro da Polícia

Militar, declarou, perante a autoridade policial (fls. 03), que: "realizavam patrulhamento pelo bairro Santa Ifigênia, na cidade de Olímpia, quando na rua Amélia Rodrigues Puttini, cruzamento com a rua Miguel Said Aidar, avistaram André entregando algo para um motociclista, quando então procederam abordagem em André, enquanto que o motociclista se evadiu sem ser identificado, oportunidade em que procedida revista pessoal, encontraram em seu poder, mais precisamente no bolso de sua bermuda, 09 (nove) pinos plásticos, contendo cocaína em seu interior e ainda uma cédula de vinte reais que André 'dispensou' quando percebeu que seria abordado. Durante a abordagem feita em André, uma mulher conhecida nos meios policiais se aproximou, sendo identificada como Sara Nery da Rocha, companheira de André, a qual ao perceber que também seria revistada, repentinamente pegou uma sacolinha plástica que estava ao lado de um poste na via pública, empreendendo fuga, ocasião em que a depoente foi em seu encalço, conseguindo detê-la com o apoio de outra guarnição, quando conseguiu detê-la, tendo Sara "dispensado" aquela sacola plástica, onde em seu interior estavam acondicionados 40 (quarenta) pinos plásticos, também contendo cocaína em seu interior e idênticos aos pinos plásticos que foram localizados em poder de André. Diante do exposto, deram voz de prisão para o casal André e Sara, conduzindo-os até esta Unidade Policial." Em Juízo, confirmou as suas declarações extrajudiciais.

* Sr. André de Jesus Sartorelio:

O acusado foi ouvido pela autoridade policial (fls. 04).

Exerceu o direito de permanecer calado (silêncio).

Confessou, todavia, em Juízo (v. TA).

"Por ocasião dos fatos, trazia consigo, para consumo alheio, drogas, quando foi abordado por membros da Polícia Militar. Por dificuldade financeira, decidiu comercializar há aproximadamente 3 (três) meses. A coacusada era sua companheira (ou namorada). Durante a diligência estatal, a coacusada aproximou-se e, ao pegar a sacola plástica com drogas que estava no chão, quis ajudá-lo. Não alegou nada pessoal contra os membros da Polícia Militar inquiridos."

* Sr.^a Sara Nery da Rocha:

A acusada foi ouvida pela autoridade policial (fls. 05).

Exerceu o direito de permanecer calada (silêncio).

Confessou, todavia, em Juízo (v. TA).

"Por ocasião dos fatos, aproximou-se do lugar dos fatos, onde o coacusado estava a ser abordado por membros da Polícia Militar. O coacusado era seu 'ficante' (sic). Durante a diligência estatal, pegou a sacola plástica com drogas, que estava no chão, e começou a correr. Não alegou nada pessoal contra os membros da Polícia Militar inquiridos."

Pois bem.

Em capítulos distintos, disserto.

2.1.1Do tráfico ilícito de drogas

Nos termos do art. 33, caput, da LD, "importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com

determinação legal ou regulamentar", configura o crime de tráfico ilícito de drogas.

O tipo penal, vejam, é "importar" (fazer vir; trazer, introduzir mercadorias de outro País), "exportar" (enviar, remeter, vender para fora do País ou do Estado), "remeter" (mandar; enviar; recomendar; fazer entrega; expedir; encaminhar; destinar), "preparar" (aprontar; arranjar; obter [um corpo qualquer] por meio de composição ou decomposição; compor; dosear; urdir; maquinar; pôr em condições de servir; predispor), "produzir" (dar origem a; causar; fabricar), "fabricar" (produzir na fábrica; manufaturar, preparar; inventar; engendrar), "adquirir" (obter; comprar; aquisitar), "vender" (alienar; ceder por certo preço; trocar por dinheiro; negociar; não conceder gratuitamente; sacrificar por dinheiro ou por interesse; entregar mediante remuneração; dispor do que possui a troco de dinheiro), "expor à venda" (apresentar; mostrar), "oferecer" (dar; facultar; levar à presença de; mostrar), "ter em depósito" (pôr em depósito; armazenar; guardar [em lugar seguro]; dar a guardar temporariamente), "transportar" (conduzir; levar de um lugar para outro; enlevar; arrebatado; transpor), "trazer consigo" (conduzir ou transportar para cá; fazer-se acompanhar), "guardar" (vigiar; vigilar; conservar; manter), "prescrever" (receitar; ministrar), "ministrar" (prestar; fornecer; aplicar), "entregar" (dar; ceder; confiar) "a consumo" (elemento subjetivo específico [pela interpretação contextual]) ou "fornecer" (promover; abastecer; garantir; ministrar; proporcionar ou ministrar o necessário a) "drogas" (as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União [art. 2º da LD]), "ainda que gratuitamente" (animus sine lucro captando), "sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar" (elemento normativo).

A redação do art. 33, caput, da LD, diferentemente do disposto nos arts. 28, caput (porte ilícito de drogas para consumo pessoal), e 33, § 1º, III (utilização ilícita de bem para o tráfico ilícito de drogas ou com o seu consentimento), da LD, não descreve elemento subjetivo específico do tipo, mas há consenso doutrinário (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 4.ª edição – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. BACILA, Carlos Roberto; RANGEL, Paulo. Comentários penais e processuais penais à lei de drogas. – 1.ª edição – Rio de Janeiro: Lumen Jûris, 2007. MORAES, Alexandre de; SMANIO, Gianpaolo Poggio. Legislação penal especial. 7.ª edição – São Paulo: Atlas, 2004. MARCÃO, Renato. Tóxicos: lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 – nova lei de drogas. – 4.ª edição – São Paulo: Saraiva, 2007. JESUS, Damásio de. Lei antidrogas anotada – comentários à lei n. 11.343/2006. – 9.ª edição – São Paulo: Saraiva, 2009. GOMES, Luiz Flávio; BIANCHINI, Alice, CUNHA, Rogério Sanches, OLIVEIRA, William Terra de. Lei de drogas comentada. 3.ª edição – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008), referendado pela jurisprudência (STF – Primeira Turma – Habeas Corpus 69.806-GO – Rel. Min. Celso de Mello, DJ, Seção I, 04/06/1993; STJ – Sexta Turma – AREsp 1.790.656-SC – Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, p. 03; TJSP – 2ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0011586-45.2010.8.26.0564 – Rel. Des. Paulo Rossi, V.U., j. 20/06/2011; TJGO – ACrim. n. 33578-9/213 – Rel. Des. Jamil Pereira de Macedo, DJGO 11/11/2008; RT 729/542 e 114/357), de que, para a caracterização do crime de tráfico ilícito de drogas, exige-se a vontade de participar da produção e da circulação de drogas (a intenção de comercializar drogas ilícitas).

Não se exige, todavia, a exteriorização do ato (traditio) concreto de comércio (TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0002166-76.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. AGUINALDO DE FREITAS FILHO, V.U., j. 21/08/2019, p. 11).

Por se tratar de infração permanente (TJSP – 13ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500168-08.2020.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. XISTO ALBARELLI RANGEL NETO, V.M., j. 18/04/2022,

p. 03/04), entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência (art. 313 do CPP).

Das dezoito condutas descritas no art. 33, caput, da LD (tráfico ilícito de drogas), o art. 28, caput, da LD (porte ilícito de drogas para consumo pessoal) descreve cinco idênticas (adquirir, guardar, ter em depósito, transportar e trazer consigo).

Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal (art. 28, caput, da LD), ou alheio (art. 33, caput, da LD), o que não é tarefa fácil, o magistrado atenderá, ao proferir a sentença de mérito, às circunstâncias estabelecidas no art. 28, § 2º, da LD (critérios valorativos), e não ao conhecimento (avaliação pessoal) dos agentes de segurança pública a respeito da fama da parte ré (odioso critério subjetivo) (STJ - Sexta Turma - AREsp 1.790.656-SC - Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, p. 04).

O magistrado não julga pessoas, mas atos e fatos.

"E a fama está marcada pela ideia de reputação, aquilo que se diz de alguém" (CORTELLA, Mário Sérgio. Pensar bem nos faz bem!: 2. família, carreira, convivência e ética - 3. ed. - Petrópolis, RJ: Vozes, 2015 - São Paulo, SP: Ferraz e Cortella, 2014, p. 105).

Não são excludentes, consigno, os tipos penais relativos ao tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da LD) e ao porte ilícito de drogas para consumo pessoal (art. 28, caput, da LD) (TJSP - 3ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000357-36.2015.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. JAIME FERREIRA MENINO, V.U., j. 10/09/2019, p. 14).

A coincidência das figuras é comum (TJSP - 6ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1501810-36.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. MARCOS ANTÔNIO CORREA DA SILVA, V.U., j. 10/06/2021, p. 08).

"Existe a possibilidade de critério para se imaginar a justeza de uma guerra. Talvez se dissesse que, na guerra contra o tráfico, na guerra contra a bandidagem, na guerra contra a corrupção, aí, sim, há uma justeza porque a causa é nobre" (CORTELLA, Mário Sérgio. Pensar bem nos faz bem!: 2. família, carreira, convivência e ética - 3. ed. - Petrópolis, RJ: Vozes, 2015 - São Paulo, SP: Ferraz e Cortella, 2014, p. 106).

Valho-me, pois, dessa explicação.

Ao lado da confissão dos acusados (art. 65, III, d, do CP), entendo que, a considerar o quadro de provas produzido, as declarações das testemunhas inquiridas, contra quem não há alegação pessoal argüida (TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1502980-77.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. SILMAR FERNANDES, V.U., j. 10/02/2020, p. 06), merecem irretocável credibilidade deste magistrado.

Não há motivo fundado para desacreditá-las (TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1500329-52.2019.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. FERNANDO GERALDO SIMÃO, V.U., j. 14/10/2021, p. 08; STJ - Quinta Turma - AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO - Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, j. 14/06/2022 ["Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese."]), penso.

Regularmente periciadas (LPTox), as drogas localizadas e apreendidas são proscritas

pela Portaria MS/SVS n. 344/1998 – Anexo Lista F1, item 11 (COCAÍNA [substância entorpecente de uso proscrito no Brasil], classificado o crack como subproduto).

A título de argumentação (ad argumentandum), o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Damião Pinheiro Machado Cogan anotou que "um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0 g do entorpecente, uma fileira de cocaína é confeccionada com 0,100 a 0,125 gramas da droga, aproximadamente" (TJSP – 5ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000638-88.2018.8.26.0588 – Rel. Des. José Damião Pinheiro Machado Cogan, V.U., j. 17/06/2019), de modo que, no presente caso dos autos, as drogas apreendidas não constituem evidentemente pequena quantidade e, de acordo com a experiência forense, são incompatíveis com a hipótese de simples uso (TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0002613-30.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. ROBERTO PORTO, V.U., j. 10/09/2019, p. 04/05).

Assim, convenço-me que o acusado André de Jesus Sartorelio, nas circunstâncias de tempo e lugar denunciadas, trazia consigo, para consumo alheio (vontade de participar da produção e da circulação de drogas), as drogas apreendidas (AEA [individualizadas]), indevidamente (sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar), e, nesse contexto, a coacusada Sara Nery da Rocha concorreu dolosamente para tanto (arts. 18, I, e 29, caput, do CP), na medida em que, ao colaborar de alguma forma – ao pegar a sacola plástica com drogas que o acusado trazia consigo, correr e dispensá-la a fim de assegurar a impunidade do crime ou, ainda, a detenção das mesmas – com a execução do crime (auxílio propriamente material), aderiu subjetivamente até à consumação da conduta criminosa do acusado André de Jesus Sartorelio (TJSP – 11ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0009337-89.2014.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel.^a Des.^a Designada MARIA TEREZA DO AMARAL, V.M., j. 30/11/2016, p. 05) e, na medida de sua culpabilidade, incide no preceito secundário à esta cominado (art. 29, caput, do CP).

De rigor, pois, a condenação dos réus.

Eis o meu convencimento.

2.1.2 Das circunstâncias agravantes

Desse contexto, reconheço, embora não tenha sido alegado (art. 385 do CPP) (TJSP – 15ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500256-32.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. GILDA CERQUEIRA ALVES BARBOSA AMARAL DIODATTI, V.U., j. 05/08/2021, p. 08 ["não há que se falar em nulidade de capítulo da sentença por violação ao princípio da congruência"]), ter a parte ré cometido o crime em ocasião de calamidade pública (art. 61, II, j. 4ª figura, do CP) (Decreto presidencial n. 10.308, de 2 de abril de 2020) (TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500574-78.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. TOLOZA NETO, V.U., j. 22/02/2022, p. 09/10; TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500095-85.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. EUVALDO CHAIB, V.U., j. 15/12/2021, p. 06/09; TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1501475-80.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ANTÔNIO CARLOS MACHADO DE ANDRADE, V.U., j. 02/12/2021, p. 04; TJSP – 14ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500865-15.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. WALTER DA SILVA, V.U., j. 23/02/2021, p. 03), porquanto, ao aproveitar-se da situação trágica (fato que envolve muitas pessoas), demonstrou desprezo (pouco-caso, desamor) solidário e fraternal; enfim, externou insensibilidade coletiva.

O período de restrição sanitária (coronavírus [Covid-19]), mesmo após o término da

vigência do Decreto presidencial, perdura infelizmente (TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500574-78.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. TOLOZA NETO, V.U., j. 22/02/2022, p. 09/10; STF – Tribunal Pleno – ADI 6625-DF – Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJ 08/03/2021), de sorte que há possibilidade da aplicação da circunstância agravante.

No entender deste magistrado, a redação do art. 61, II, j, do CP não traz nenhum requisito disciplinador, limitando-se a punir mais gravemente o cometimento do crime em ocasião de calamidade pública (objetividade temporal).

"Trata-se, portanto, de agravante de natureza objetiva" (TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500095-85.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. EUVALDO CHAIB, V.U., j. 15/12/2021, p. 06/09).

2.1.3 Da associação para o tráfico ilícito de drogas

Nos termos do art. 35, caput, da LD, "associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 'da Lei de Drogas'", configura o crime de associação para o tráfico ilícito de drogas.

O tipo penal, vejam, é "associarem-se" (reunirem-se, juntarem-se, com ânimo de associação, de caráter duradouro e estável) "duas ou mais pessoas" (plurissubjetividade) "para o fim de praticar" (elemento subjetivo específico [finalidade associativa]), "reiteradamente ou não" (habitualidade ou eventualidade executiva), "qualquer dos crimes" apontados com taxatividade pela Lei de Drogas (finalidade associativa).

O que diferencia o crime de associação criminosa específica do tráfico ilícito de drogas (art. 35, caput, da LD) do concurso de pessoas (art. 29 do CP) é o elemento subjetivo (animus) dos sujeitos ativos do crime.

Exige-se, para a configuração do crime de associação criminosa, a demonstração concreta do vínculo de estabilidade e permanência (associatividade), diferentemente do concurso de pessoas.

Não é suficiente a união ocasional, eventual e episódica.

Para determinar se a reunião era, ou não, eventual, o que não é tarefa fácil, o magistrado atenderá, ao proferir a sentença de mérito, às circunstâncias comportamentais dos sujeitos ativos do crime (critério objetivo), e não ao conhecimento (avaliação pessoal) dos agentes de segurança pública a respeito da fama dos sujeitos ativos (odioso critério subjetivo) (STJ – Sexta Turma – AREsp 1.790.656-SC – Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, p. 04)

O magistrado não julga pessoas, mas atos e fatos.

"E a fama está marcada pela ideia de reputação, aquilo que se diz de alguém" (CORTELLA, Mário Sérgio. Pensar bem nos faz bem!: 2. família, carreira, convivência e ética – 3. ed. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2015 – São Paulo, SP: Ferraz e Cortella, 2014, p. 105).

Não se exige, para a configuração deste crime autônomo, a efetiva prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da LD), equiparado ao tráfico ilícito de drogas (art. 33, § 1º, da LD) ou de tráfico ilícito de maquinismos relacionados ao processamento de drogas (art. 34, caput, da LD).

Daí ser desnecessário apreender a droga ou examiná-la.

Valho-me, pois, dessa explicação.

Nos termos do art. 156, caput, do CPP, "a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: I - ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida; II - determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante."

Por outras palavras, o ônus da prova incumbe ao autor da ação penal, quanto ao fato constitutivo de seu direito (a prova incriminadora [a ocorrência do contexto criminoso, de acordo com a descrição na petição inicial da ação penal, a autoria delitiva, a materialidade dos fatos e eventuais dados circunstanciais alegados]) (TJSP - 2ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1500406-47.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ALEX TADEU MONTEIRO ZILENOVSKI, V.U., j. 06/06/2022, p. 05).

A denúncia, em relação ao contexto fático, é retrospectiva (aspecto subjetivo), mas, em relação às provas, é prospectiva (fonte [aspecto objetivo]) (TJSP - 5ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 0004887-69.2015.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO, V.U., j. 12/06/2022, p. 12 ["... os elementos colhidos a esse título autorizam a condenação do agente, porque os indícios fortalecem o fato indicativo, no âmbito meramente subjetivo da prova, e, além disso, fortalecem o conteúdo dela, agora considerado o seu aspecto objetivo."]; TJSP - 6ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1500531-44.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. FARTO SALLES, V.U., j. 24/06/2022, p. 08), esclareço.

E, nesse aspecto, o Ministério Público (Parquet), posto (apesar de) alegar, não demonstrou a prova incriminadora (contexto fático constitutivo do seu direito).

Os indícios colhidos fora de juízo (fase policial ou inquisitorial), os quais legitimaram o oferecimento e o recebimento da denúncia em face dos acusados pela prática do contexto fático previsto no art. 35, caput, da LD (associação para o tráfico ilícito de drogas), consigno, não foram, à luz dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), confirmados de forma segura e indene de dúvida (art. 386, VII, do CPP) (STJ - 5ª Turma - AgRg no HC n. 300.212/SP - Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 27/10/2015, DJe de 04/11/2015; STJ - 5ª Turma - HC n. 286.582/SP - Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 04/10/2016, DJe de 11/10/2016; STJ - 5ª Turma - HC n. 353.232/MG - Rel. Min. JORGE MUSSI, j. 28/6/2016, DJe de 1º/08/2016).

O quadro de provas produzido não é bastante (suficiente).

No presente caso dos autos, não há, no pensar deste magistrado, elementos devidamente caracterizados a demonstrar concretamente o caráter associativo da convergência de vontades (animus manendi, intenção de permanecer, ânimo associativo) de se praticar um número indefinido de crimes de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da LD) (TJSP - 3ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 0000109-65.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. XISTO ALBARELLI RANGEL NETO, V.U., j. 22/01/2020, p. 06), como, por exemplo (verbi gratia), a confluência dos diálogos (correspondência) e o conteúdo das comunicações (thema).

Não existe prova suficiente (bastante, necessária) de que se tratava de reunião estável e permanente (TJSP - 1ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 0003398-60.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de

Olímpia - Rel. Des. PÉRICLES PIZA, V.U., j. 12/08/2019, p. 11).

O contato (interação) dos acusados, em que pese a relação familiar de coabitação (TJSP - 13ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1501130-17.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. XISTO ALBARELLI RANGEL NETO, V.U., j. 10/05/2021, p. 06/07 [... nada se investigou sobre mais do que a coautoria, não sendo bastante a mera suspeita de associação permanente, ainda que se tome em consideração o fato de os dois estarem praticando o tráfico de drogas no âmbito familiar."]), era meramente ocasional ou episódico.

Não era um verdadeiro pacto associativo, acerto.

Não está evidente a intenção de reiteração delituosa.

Descaracterizada, pois, a associação criminosa específica.

De rigor, pois, a absolvição (art. 386, VII, do CPP).

Eis o meu convencimento.

2.2 Dos elementos do crime

No que se refere ao FATO TÍPICO, a descrição (conduta dolosa - resultados normativo e naturalístico - nexos de causalidade) atribuída à parte ré, contida na denúncia, adequa-se tipicamente (tipicidade), de acordo com os fundamentos desta sentença, no art. 33, caput, da LD.

No que se refere à ILICITUDE, o contexto fático típico (injusto penal) praticado pela parte ré (tráfico ilícito de drogas), em razão da lesão aos bens jurídicos tutelados (a saúde pública, primariamente, e a vida, a saúde pessoal e a família [STF, RT 618/407; TJSP - Câmara Especial - Apelação Cível n. 1500148-37.2019.8.26.0400, do Anexo da Vara da Infância e da Juventude, Atos Infracionais e Medidas Sócio-educativas da Comarca de Olímpia - Rel. Des. RENATO GENZANI FILHO, V.U., j. 15/01/2020, p. 07], secundariamente), é contrário ao ordenamento jurídico, não se identificando, nos autos, nenhuma causa excludente.

A perversidade do tráfico ilícito de drogas destrói a base da sociedade (art. 226, caput, da CF), que, pelos efeitos permanentes (dependências física e psicológica) da infração penal praticada pela parte ré, sente a desordem concreta (palpável), e sem ordem não há progresso.

Nos termos do art. 24, caput, do CP, "considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual ou iminente, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se", de modo que, no presente caso dos autos, ao comparar os bens salvo (dificuldade financeira [sic], de interesse particular) e sacrificado (saúde pública, de interesse da sociedade), este é de maior importância que aquele, o que afasta, pelo princípio da ponderação de bens, a "inexigibilidade do sacrifício do bem ameaçado" (TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0003837-71.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. EDUARDO ABDALLA, V.U., j. 23/05/2018, p. 04).

No que se refere à CULPABILIDADE, a parte ré era imputável, detinha possibilidade de compreender a ilicitude de sua conduta e, na situação em que se encontrava, podia ser exigido dela comportamento diferente, não se vislumbrando, nos autos, nenhuma causa excludente.

2.3 Da aplicação da pena

Esclareço, inicialmente, que a pena-base será fixada (I) atendendo-se aos critérios do art. 59 do CP e art. 42 da LD (denominados pela doutrina de “circunstâncias judiciais”), com preponderância deste em relação àquele (STJ – Habeas Corpus n. 688.099-SP, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS, j. 11/03/2022, p. 04; TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1501137-43.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. EDISON APARECIDO BRANDÃO, V. U., j. 22/03/2021, p. 10); (II) em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; (III) por último, as causas de diminuição e de aumento.

Pois bem, considerando o preceito secundário do contexto criminoso processado e julgado – Tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da LD): 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa –, passo a fixá-lo, pelo princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) (TJSP – 10ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0000015-59.2014.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. FRANCISCO JOSÉ GALVÃO BRUNO, V.U., j. 23/05/2019, p. 04), separadamente.

Do réu André de Jesus Sartorelio

Antes, porém, sintetizo os dados processuais da parte ré:

Tempo do fato: 27/04/2021

Folha de Antecedentes

Autos
(referência)

Data do fato
(específica)

T. em julgado (processo)

Certidão
Criminal

T. em julgado (extinção)

Classificação
penal

387 (1)
3768-20/2008
27/10/2007
22/06/2009
371/372
28/01/2019 (fls. 372)
Reincidência
387 (2)

6464.63/2007
19/04/2007
10/08/2010
372/373
28/01/2019 (fls. 373)
Reincidência
388 (3)
49513-28/2010
19/12/2010
17/04/2012
375/376
18/02/2019 (fls. 386)
Reincidência
específica

A considerar esse quadro descritivo (TJSP - 1ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1500192-56.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. LUIZ ANTONIO FIGUEIREDO GONÇALVES, V.U., j. 08/05/2021, p. 06; TJSP - 6ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 0000753-62.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. MARCOS CORREA, V.U., j. 11/07/2022, p. 03/04 ["O magistrado fez uma tabela informando didaticamente quais condenações utilizou para efeito de maus antecedentes e quais utilizou para efeito de reincidência."]), início a dosimetria.

Com relação aos CRITÉRIOS DOS ARTIGOS 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI DE DROGAS, entendo que, sopesando ambas as disposições legais, (i) a culpabilidade, (ii) a natureza do produto entorpecente e (iii) os antecedentes são desfavoráveis à parte ré, de modo que fixo a pena-base, majorando-a de 3/6 (três sextos), em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

A justificar a base penal fixada acima do mínimo cominado, CONSIDERO, atribuindo-se, para cada circunstância, a fração mínima estabelecida pelo Código Penal (1/6) (TJSP - 3ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 0005610-20.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ANTÔNIO ÁLVARO CASTELLO, V.U., j. 28/09/2020, p. 17 [1/6]), os itens judiciais apontados. Explico:

Da culpabilidade: No entender deste magistrado, o contexto criminoso apresenta elevadíssimo grau de reprovabilidade e censurabilidade, na medida em que a localização geográfica do Parque Aquático Thermas dos Laranjais, na região da Comarca da Estância Turística de Olímpia (localizada nas proximidades da divisa dos Estados de São Paulo e Minas Gerais, às margens do Rio Grande), o parque aquático mais visitado do Brasil e da América Latina e o 4º mais visitado em todo o mundo (em 2018, mais de 2,6 milhões de visitantes), ao contrário de outras Comarcas, desperta a prática da traficância, aptidão atrativa (vis atractiva) essa que não pode ser ignorada pelo Estado, de modo a transformar os agentes públicos, no jargão forense, "enxugadores de gelo", pois o comportamento em questão, infelizmente, mostra-se bastante acentuado na região noroeste paulista (TJSP - 2ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0004636-51.2015.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ALEX ZILENOVSKI, V.U., j. 27/11/2016, p. 06; TJSP - 3ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500225-46.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. JAYME WALMER DE FREITAS, V.U., j. 22/22/2022, p. 08 ["Pondere-se que essa alta culpabilidade, em nosso sentir, deveria caracterizar circunstâncias do crime. Vale dizer, a traficância em local tão visitado merecia majoração desta circunstância, com a devida vênia, pois a comercialização para tamanho público seria bem mais facilitada. De todo modo, o aumento à pena-base tem fundamento e merece ser mantido."]; TJSP - 3ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500061-32.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia -

Rel. Des. ANTÔNIO ÁLVARO CASTELLO, V.U., j. 21/08/2020, p. 08; TJSP - 3ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0005627-90.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO, V.U., j. 31/07/2018, p. 03; TJSP - 4ª Câmara de Direito Criminal - Apelações n. 0002510-23.2018.8.26.0400 e n. 0000218-65.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. LUÍS SOARES DE MELLO NETO, V.U., j. 06/04/2020 e j. 12/10/2019, p. 09, respectivamente; TJSP - 4ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000524-82.2017.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel.ª Des.ª IVANA DAVID, V.U., j. 22/10/2019, p. 05; TJSP - 4ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000382-78.2017.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ROBERTO TEIXEIRA PINTO PORTO, V.U., j. 24/09/2019, p. 06; TJSP - 4ª Câmara de Direito Criminal - Apelações n. 1500348-58.2019.8.26.0557 e n. 0000733-71.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. EUVALDO CHAIB FILHO, V.U., j. 15/04/2020 e j. 11/12/2018, p. 05 e 04, respectivamente; TJSP - 5ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0003945-03.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel.ª Des.ª CLÁUDIA LÚCIA FONSECA FANUCCHI, V.U., j. 12/02/2019, p. 08; TJSP - 6ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1501167-78.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. FARTO SALLES, V.U., j. 08/04/2022, p. 10; TJSP - 6ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1501810-36.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. MARCOS ANTÔNIO CORREA DA SILVA, V.U., j. 10/06/2021, p. 09; TJSP - 6ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0003377-84.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. EDUARDO CRESCENTI ABDALLA, V.U., j. 04/11/2020, p. 05; TJSP - 6ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0001150-53.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA, V.U., j. 07/10/2019, p. 04; TJSP - 6ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000097-71.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ANTÔNIO CARLOS MACHADO DE ANDRADE, V.U., j. 31/01/2019, p. 09; TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500017-62.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. AGUINALDO DE FREITAS FILHO, V.U., j. 11/04/2022, p. 18/19; TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0001633-83.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ALBERTO ANDERSON FILHO, V.U., j. 13/03/2019, p. 05; TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0003837-71.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. EDUARDO CRESCENTI ABDALLA, V.U., j. 23/05/2018, p. 05; TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0003167-18.2013.8.26.0439, da 1ª Vara da Comarca de Pereira Barreto - Rel. Des. ROBERTO MORTARI, V.U., j. 5/03/2015; TJSP - 8ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0001092-50.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ALEXANDRE CARVALHO E SILVA DE ALMEIDA, V.U., j. 06/02/2020, p. 08; TJSP - 8ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000492-77.2017.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. JÚLIO CAIO FARTO SALLES, V.U., j. 26/09/2019, p. 05; TJSP - 8ª Câmara de Direito Criminal - Apelações n. 0001091-36.2016.8.26.0400 e n. 0000995-50.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. SÉRGIO ANTÔNIO RIBAS, V.U., j. 4/10/2018 e j. 12/03/2020, p. 11 e p. 09, respectivamente; TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500221-57.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ROBERTO GRASSI NETO, V.U., j. 20/04/2020, p. 07; TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1502716-60.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ANDRADE SAMPAIO, V.U., j. 06/04/2020, p. 09; TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000219-84.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ALCIDES MALOSSI JÚNIOR, V.U., j. 31/10/2019, p. 24; TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1502980-77.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. SILMAR FERNANDES, V.U., j.

10/02/2020, p. 09; TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500770-82.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel.ª Des.ª FÁTIMA GOMES, V.U., j. 31/03/2022, p. 10/11; TJSP - 10ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0003374-61.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. FRANCISCO JOSÉ GALVÃO BRUNO, V.U., j. 13/02/2020, p. 04; TJSP - 11ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0005553-02.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ABEN-ATHAR DE PAIVA COUTINHO, V.U., j. 04/09/2019, p. 02; TJSP - 11ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000369-16.2016.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel.ª Des.ª MARIA TEREZA DO AMARAL, V.U., j. 17/10/2018, p. 04; TJSP - 13ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0005390-56.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA, V.U., j. 06/12/2018, p. 10; TJSP - 14ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1501960-17.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. MIGUEL MARQUES E SILVA, V.U., j. 25/11/2021, p. 06; TJSP - 14ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500733-06.2019.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. WALTER DA SILVA, V.U., j. 27/02/2021, p. 03 ["havendo ampla fundamentação do Juízo nesse sentido."]; TJSP - 14ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000103-44.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. HERMANN HERSCHANDER, V.U., j. 06/12/2018, p. 04; TJSP - 15ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1501791-30.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. CLAUDIO LIMA BUENO DE CAMARGO, V.U., j. 10/02/2022, p. 03/04; TJSP - 15ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0002764-64.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. CLÁUDIO MARQUES, V.U., j. 29/11/2018, p. 04; TJSP - 16ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0001464-96.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. OTÁVIO AUGUSTO DE ALMEIDA TOLEDO, V.U., j. 07/08/2019, p. 06; TJSP - 16ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0900341-28.2012.8.26.0439, da 1ª Vara da Comarca de Pereira Barreto - Rel. Des. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, V.U., j. 11/06/2013).

Da natureza do produto entorpecente: No entender deste magistrado, é altamente lesiva a natureza da droga apreendida (LPTox [Benzoilmetilecgonina, conhecida popularmente por cocaína, classificado o crack - droga dentre as piores espécies que existem - como subproduto]), cujas consequências, quando ministradas no ser humano, são devastadoras (STJ - Habeas Corpus n. 688.099-SP, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS, j. 11/03/2022, p. 05; STJ - Quinta Turma - AgRg no Habeas Corpus n. 583.833-SP - Rel. Min. FÉLIX FISCHER, V.U., j. 18/08/2020, p. 01 [item III da ementa]; TJSP - 3ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500061-32.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. ANTÔNIO ÁLVARO CASTELLO, V.U., j. 21/08/2020, p. 08; TJSP - 3ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0001146-55.2014.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. TOLOZA NETO, V.U., j. 06/11/2018, p. 08; TJSP - 4ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000033-41.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. EDISON APARECIDO BRANDÃO, j. 09/04/2019, p. 07; TJSP - 4ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0002613-30.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. ROBERTO PORTO, V.U., j. 10/09/2019, p. 04; TJSP - 4ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0003231-77.2015.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. IVAN SARTORI, V.U., j. 28/08/2018; TJSP - 5ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0002297-17.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. MAURÍCIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO, V.U., j. 17/10/2019, p. 08; TJSP - 6ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1501167-78.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. FARTO SALLES, V.U., j. 08/04/2022, p. 11/12; TJSP - 8ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000492-77.2017.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. JÚLIO CAIO

FARTO SALLES, V.U., j. 26/09/2019, p. 06; TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000047-59.2017.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. CARLOS EDUARDO ANDRADE SAMPAIO, V.U., j. 21/02/2019, p. 10; TJSP - 14ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000206-65.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. MARCO ANTÔNIO DE LORENZI, V.U., j. 10/10/2019, p. 03; TJSP - 15ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0007365-55.2012.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel.^a Des.^a GILDA CERQUEIRA ALVES BARBOSA AMARAL DIODATTI, V.U., j. 03/10/2019, p. 08).

Dos antecedentes: A parte ré apresenta dados desabonadores - ou seja, sentença penal condenatória transitada em julgado (v. quadro descritivo) - da vida pregressa.

A reincidência - que significa, em sentido largo (lato sensu), antecedente criminal - pode ser considerada como circunstância judicial, desde que não o seja, simultaneamente, como circunstância agravante (Súmula 241 do STJ).

"Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente" (STJ - Terceira Seção - RESp 1.794.854/DF - Rel.^a Min.^a LAURITA VAZ, V.U., j. 23/06/2021 [item 9] [Tema 1.077]).

Com relação às CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES, da leitura dos autos confrontada com os arts. 61, 62 e 65 do CP, de um lado, a parte ré confessou espontaneamente, perante a autoridade, a autoria delitiva (art. 65, III, d, do CP e Súmula 545 do STJ), e, de outro, é reincidente por uma vez (v. quadro descritivo) (arts. 61, I, 63 e 64, I, do CP), reincidente específico por uma vez (v. quadro descritivo) (arts. 61, I, 63 e 64, I, do CP) e cometeu o crime em ocasião de calamidade pública (art. 61, II, j, do CP), de modo que, neutralizada a primeira circunstância com a segunda (TJSP - 1ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0001443-91.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. DINIZ FERNANDO, V.U., j. 27/08/2018; TJSP - 10ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0003101-19.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. FRANCISCO JOSÉ GALVÃO BRUNO, V.U., j. 23/07/2020, p. 04; TJSP - 11ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0001230-17.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. NILSON XAVIER DE SOUZA, V.U., j. 15/05/2019, p. 03; TJSP - 14ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0006205-24.2014.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. WALTER DA SILVA, V.U., j. 05/07/2018; TJSP - 16ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0001125-74.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. CAMARGO ARANHA FILHO, V.U., j. 16/04/2019, p. 06), fixo a pena provisória, com agravamento de 3/6 (três sextos), em 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão e 1.125 (mil e cento e vinte e cinco) dias-multa.

Respeitado entendimento diverso, o tratamento diferenciado da circunstância agravante da reincidência específica é justo, proporcional, razoável e, sobretudo, constitucional (art. 5º, XLVI, da CF) (TJSP - 3ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1501944-97.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Estância Turística de Comarca de Olímpia - Rel. Des. CÉSAR MECCHI MORALES, V.U., j. 12/01/2021, p. 06; TJSP - 3ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 0000109-65.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. XISTO ALBARELLI RANGEL NETO, V.U., j. 22/01/2020, p. 08; TJSP - 5ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0008312-75.2013.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. MAURÍCIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO, V.U., j. 27/07/2020, p. 09 [1/3]; TJSP - 5ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0003985-48.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel.^a Des.^a CLÁUDIA LÚCIA FONSECA FANUCCHI, V.U., j. 24/07/2019, p. 08; TJSP - 6ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0002059-32.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de

Olímpia - Rel. Des. RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA, V.U., j. 06/03/2020, p. 05; TJSP - 6ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000097-71.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. ANTONIO CARLOS MACHADO DE ANDRADE, V.U., j. 31/01/2019, p. 09; TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0001243-16.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. EDUARDO ABDALLA, V.U., j. 07/08/2019, p. 03; TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500221-57.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ROBERTO GRASSI NETO, V.U., j. 20/04/2020, p. 08; TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0003452-89.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. SÉRGIO COELHO, V.U., j. 7/02/2019, p. 11; TJSP - 10ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0003101-19.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. FRANCISCO JOSÉ GALVÃO BRUNO, V.U., j. 23/07/2020, p. 04 [1/3]; TJSP - 11ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000369-16.2016.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. MARIA TEREZA DO AMARAL, V.U., j. 17/10/2018, p. 04; TJSP - 15ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500920-97.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. CLÁUDIO ANTONIO MARQUES DA SILVA, V.U., j. 30/10/2020, p. 04 [1/3]).

Com relação às CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO, não reconheço nenhuma, de modo que mantenho a pena provisória nos marcos fixados até então.

A biografia criminal da parte ré impede o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da LD (TJSP - 4ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1501721-13.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. EUVALDO CHAIB, V.U., j. 14/07/2021, p. 05).

Em conclusão, nos termos do art. 68, caput, do CP, fixo a PENA DEFINITIVA em 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão